

1506233-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... as provas para condenação por tráfico, postulando a absolvição com fundamento no artigo 386, V ou VII, do CPP. No mais, a Defesa postula por fixação da pena no mínimo legal, aplicação da redutora do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial diverso do fechado para cumprimento de pena. O último pleito defensivo é por concessão de eventual recurso ao acusado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1506233-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069585/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23569002 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2069585 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO ROGERIO NUNES DE SOUZA

Vítima:

Saúde Pública

1. INÍCIO: A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 09 de agosto de 2022, às 13 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. DANIELA MOISES DA SILVEIRA FAVARO.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR - DEFENSORA PÚBLICA.

C. Acusado: CLAUDIO ROGERIO NUNES DE SOUZA ausente.

D. Testemunhas: DAMIÃO ALBERTO DE SOUSA FERREIRA e ROBSON LEANDRO RODRIGUES DE MIRANDA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Pelo mm. Juiz foi decretada a revelia do acusado, pois não foi localizado para ser intimado (fl. 132), nos termos do disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridos os guardas civis DAMIAO ALBERTO DE SOUSA FERREIRA e ROBSON LEANDRO RODRIGUES DE MIRANDA. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. A defesa, em complemento, apresentou memoriais escritos nos seguintes termos: MM. Juiz, ao final da instrução probatória, a ação penal merece desfecho de improcedência. De início, forçoso argumentar que a dinâmica probatória se revela inexistente diante do fato de a prisão ter ocorrido apenas e tão somente com a participação de guardas civis metropolitanos, em aparente desvio de função. Os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, não cabem às guardas municipais, a quem a Constituição legitima apenas a proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. No caso, como fica evidente, os servidores públicos exerceram tirocínio próprio da polícia para decidir a respeito de uma abordagem calcada em fundada suspeita. Ao invés de encaminhá-la àqueles que detêm competência constitucional para o ato, exerceram a busca e apreensão, apesar de inexistente urgência na medida. Trata-se, portanto, de ato de investigação que não é possível à Guarda Municipal. Poder-se-ia afirmar a legalidade da ação, visto cuidar-se de crime permanente e, portanto, a possibilidade de qualquer pessoa efetuar a prisão. Contudo, tal permissão somente existe quando não há outro meio. E, no caso em questão, de acordo com os depoimentos dos guardas, eles admitiram que realizaram a busca e apreensão porque assim entenderam se tratar de local de conhecido ponto de tráfico. Portanto, houve ato de investigação, que não se inclui na competência da Guarda Municipal. Assim preconiza o artigo 144, § 8.º da Constituição Federal, que limita a função do guarda municipal, não sendo inerente à sua função, a revista pessoal realizada por guarda municipal, sem motivo legal justificador, é ilegítima, contaminando a prova obtida, assim como o que dela derivou. Logo, a invasão ao direito constitucional à intimidade torna ilegal a revista pessoal realizada por quem não tem poderes para tal, fazendo com que suas consequências também sejam nulas. Neste sentido: "Prova Criminal. Ilícita. Ocorrência. Apreensão de 'crack'. Busca pessoal realizada por guardas municipais. Exorbitância da esfera de competência. Inteligência do art. 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Apreensão nula. Comprometimento da certeza da materialidade da infração. Absolvição mantida. Recurso não provido. Realizada por quem não tem competência legal, a busca pessoal resulta em apreensão nula, que não serve para provar posse de droga e compromete a certeza da própria materialidade da infração" (Ap. Criminal 198.513.3, Santa Bárbara D'Oeste, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Dante Busana j. 07.03.96, v.u.). Mais recentemente, a Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal assim decidiu em acórdão da lavra do Des. Márcio Bártoli, verbis: "Sob hipótese alguma, poderia tal prova - fruto de diligências investigativas realizadas em evidente desrespeito ao texto constitucional - ter sido admitida no processo e sequer poderia ter dado suporte à deflagração da ação penal. [...] Por expressa previsão constitucional, às forças policiais civil e federal fora reservada atribuição para a investigação de fatos delituosos, ao passo que à guarda municipal não fora prevista qualquer atuação em matéria de segurança pública. E, enquanto agentes administrativos, regidos pelo princípio da legalidade, só podendo atuar aonde a lei autoriza, essa falta de previsão implica verdadeira vedação de agir. [...] Guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo, atividade, repita-se à exaustão, por expressa previsão constitucional, exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do §8º do artigo 144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares." (TJSP, Apelação n. 0001118-92.2017.8.26.0526, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. MÁRCIO BÁRTOLI, j. em 16-04-2018). O guarda municipal Damião disse que estavam em policiamento preventivo na região da Cracolândia,

quando viram um aglomerado de pessoas. Réu nervoso e com certa pressa. Quando se aproximou para abordá-lo, ele dispensou uma embalagem de marmitta na qual foram encontrados os entorpecentes. Réu teria dito que receberia R\$ 50,00 para entregar essas drogas dentro do "fluxo". Réu parecia ser morador de rua, estava mal vestido, com odor forte. O próprio réu aparentava estar sob efeito de entorpecentes. No mesmo sentido foi a narrativa do guarda Robson. Sendo este todo o conjunto probatório, a Defesa entende que, no mínimo, restou duvidoso o destino de tais entorpecentes e, assim, insuficientes as provas para condenação por tráfico, postulando a absolvição com fundamento no artigo 386, V ou VII, do CPP. No mais, a Defesa postula por fixação da pena no mínimo legal, aplicação da redutora do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial diverso do fechado para cumprimento de pena. O último pleito defensivo é por concessão de eventual recurso ao acusado em liberdade." Em seguida, o mm. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou CLAUDIO ROGERIO NUNES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da lei n. 11343/06. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com a inquirição de testemunhas. O acusado, revel, não foi interrogado. Por ocasião dos debates, o Ministério Público insistiu na condenação, nos termos da denúncia, possibilitando-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11343/06. A defesa requereu a absolvição ao argumento de fragilidade probatória e, de forma subsidiária, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, além de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Encerrada a instrução, não se desincumbiu o Ministério Público do ônus probatório, de forma que a denúncia é improcedente. Com efeito, o pedido condenatório está fundado, exclusivamente, na atuação e nas declarações de guardas municipais, que não agiram em conformidade a preceitos legais e constitucionais que regulam a atuação do órgão. Em primeiro, os guardas municipais suspeitaram do acusado e decidiram abordá-lo. Em vista da iminência da abordagem, o acusado fugiu, mas foi alcançado e preso em flagrante. A Guarda Municipal, porém, não é órgão auxiliar da Polícia Militar ou da Polícia Civil e não pode, à míngua de autorização constitucional, arvorar a si a missão de preservação da ordem pública, de policiamento ostensivo ou atividade típica de polícia judiciária, como ocorreu na hipótese dos autos. A Constituição Federal, no capítulo próprio da segurança pública, estabeleceu competência específica para a Guarda Municipal: a proteção de bens, serviços e instalações municipais, na forma da lei (art. 144, § 8º). Não se vê na legislação federal que regulamenta a atuação da Guarda Municipal, sobretudo a lei n. 13022/2014, que criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e a lei n. 13.675/2018, que disciplina e organiza o funcionamento de órgãos de segurança pública, autorização para que o órgão exerça função típica da polícia militar ou civil – e nem poderia ser diferente em vista da clareza do texto constitucional. Justamente por isso, não dispõem os guardas municipais de competência administrativa para a busca pessoal, como há muito reconhece a melhor doutrina: "Os agentes autorizados a realizar busca pessoal são os que possuem a função constitucional de garantir a segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crimes polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, além dos policiais penais (art. 144, CF). Não possuem tal função os agentes das guardas municipais, logo, não estão autorizados a fazer busca pessoal" (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal, 2ª ed., Forense, 2021, p. 313-314). E, ainda: "por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes" (Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 8ª ed., RT, 2020, p. 588). Trata-se, na hipótese, de prisão decorrente de uma busca ilegal e não uma busca ilegal decorrente de uma prisão lícita: primeiro os guardas municipais efetuaram uma busca ilegal e, depois, prenderam o acusado em flagrante.

A distinção é importante, pois é sabido que os guardas municipais podem, como o pode qualquer cidadão, efetuar a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito (CPP, art. 301). Não podem, porém, como nenhum cidadão pode, executar a busca pessoal à míngua de autorização legal. Em segundo, a ilegalidade não se resume apenas a uma questão de competência para a execução da busca pessoal. O ato em si ocorreu

de forma irregular, pois não havia FUNDADA SUSPEITA para a execução de busca pessoal, como exige o Código de Processo Penal, em seu art. 244: A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Na espécie, não havia nenhum motivo para a busca pessoal, senão o fato do acusado dirigir-se ao "fluxo da cracolândia", o que revela, a bem da verdade, a atuação da guarda municipal com fundamento, apenas, na aparência e na classe social da pessoa. A esse propósito, não posso deixar de observar que o acusado é pobre e, como relatou um dos guardas, encontrava-se em situação deplorável. Registro, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão paradigmático, reconheceu como inválida a busca pessoal, sem mandado judicial, com fundamento apenas na impressão subjetiva da polícia a respeito de uma aparente atitude suspeita do indivíduo, como ocorreu na hipótese dos autos "Exige-se, em termos de standard probatório para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência (...)" (RHC 158.6850/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022). O grifo não consta no original. Na hipótese dos autos, não há nenhum outro elemento de convicção a justificar o processamento da ação penal, além da conduta ilícita dos guardas municipais, que não é passível de convalidação. Em terceiro, a denúncia narra hipótese de porte de drogas e de uma

balança de precisão para fins de tráfico e, para comprovação dos fatos alegados, o Ministério Público apresentou em juízo unicamente o testemunho dos próprios guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que é insuficiente, já que a prova está isolada e não tem amparo em outros elementos de convicção. Não se coloca em dúvida a honradez dos guardas municipais que foram inquiridos em juízo, mas a sentença condenatória não pode estar alicerçada exclusivamente nas declarações das pessoas que efetuaram a prisão em flagrante e, naturalmente, anseiam legitimar a conduta anteriormente adotada. Os guardas municipais não são suspeitos ou indignos de fé em razão da função, mas suas declarações não gozam de presunção de veracidade e legitimidade – não é correto transplantar regras de direito administrativo para o processo penal. E, de toda forma, ainda que se tratasse de processo de natureza cível, o testemunho do agente público, como ato personalíssimo, não gozaria de presunção de veracidade – trata-se, obviamente, de atributo do ato administrativo e não das declarações do agente público em procedimento judicial. Nenhuma prova testemunhal tem valor absoluto, seja a testemunha um agente de segurança pública ou um particular. Mesmo as declarações de policial militar (ou guarda municipal, como na hipótese) devem ser sopesadas em cotejo com outros elementos de convicção e, inexistindo nada mais nos autos além desse testemunho, impõe-se a absolvição por falta de provas. Importante destacar, a esse propósito, o ensinamento sempre oportuno do professor GUSTAVO BADARÓ: “se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de convicção existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si.” (Processo Penal. 8ª edição, São Paulo, 2020, p 565/566). Conclusão diversa seria absurda e acarretaria a desobrigação da polícia civil investigar os fatos, do Ministério Público de prová-los em juízo, e do julgador de motivar suas decisões – bastaria ouvir os policiais que efetuaram a prisão. A independência de todos os atores do sistema de justiça criminal, inclusive o julgador, estaria fulminada; todos se encontrariam jungidos, vinculados ao que disse o guarda municipal, que efetuou a prisão do suspeito, já que nada mais foi apresentado pela acusação. A presunção de inocência, como garantia constitucional de um Estado democrático, somente deve ceder diante da prova robusta, produzida em contraditório e assegurada a ampla defesa. Não é o que ocorreu na hipótese dos autos: nada mais foi apresentado pela acusação, além do testemunho dos guardas municipais. Em quarto, o acusado se lesionou durante a prisão e a versão apresentada pelos guardas municipais de que ele se chocou contra um poste durante a fuga, não é verossímil, haja vista a extensão das lesões, em diversas partes do corpo: “EDEMA E EQUIMOSE PERIORBITÁRIO DIREITO. FERIMENTO CONTUSO DE 2 CM, SUTURADO, LOCALIZADO NO SUPERCÍLIO DIREITO. ESCORIAÇÃO NA PARTE INTERNA DO LÁBIO INFERIOR (0,3 CM). ESCORIAÇÃO COM CROSTA SECA DESPRENDENDO-SE DA LESÃO NA REGIÃO DELTOÍDEA ESQUERDA (4CM X 0,8 CM). ESCORIAÇÃO COM CROSTA SECA DESPRENDENDO-SE DA LESÃO NA REGIÃO INFRAESCAPULAR DIREITA (4 CM X 0,5 CM). ESCORIAÇÃO COM CROSTA SECA NO JOELHO DIREITO (1 CM)” (fl. 122). Nesse caso, em se verificando possível excesso dos guardas municipais, era especialmente importante a oitiva de outras testemunhas, para não se correr o risco de legitimação de conduta ilícita e intolerável em um Estado de Direito – a atuação violenta de órgãos de repressão, porque praticada por agentes do Estado, é mais grave que o próprio tráfico de drogas. Em quinto, a versão acusatória em si parece inverossímil, porque supõe a ideia de que o acusado estaria trafegando em área com intenso policiamento (região da Cracolândia) com dezenas de porções de droga e mais uma balança de precisão dentro de um marmitex. Por tudo que foi exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e absolvo o acusado, o que faço com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do CPP. Autorizo a destruição do objeto apreendido. Publique-se.

Intime-se. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público afirmou a intenção de RECORRER, enquanto a defesa técnica o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Recebo o recurso. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para a apresentação das razões e, em seguida, à Defensoria Pública do Estado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as anotações necessárias. Sem prejuízo, expeça-se edital de intimação da sentença para o acusado revel. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto n. 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, adiante assinado digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.